



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2022-117021007- -APN-DR#CNDC s/ Solicitud de opinión consultiva COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

VISTO el Expediente N° EX-2022-117021007- -APN-DR#CNDC, la Ley N° 27.442, y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de esta Secretaría, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los artículos 7 a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta consiste en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria de la firma NEWMONT CORPORATION, en la firma MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG.

Que, previo a la operación notificada, MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, como joint venture, estaba integrada por YAMANA con una participación del CINCUENTA Y SEIS COMA VEINTICINCO POR CIENTO (56,25%), GLENCORE INTERNATIONAL AG con una participación del 25% y NEWMONT CORPORATION con una participación del DIECIOCHO COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (18,75%).

Que el 17 de septiembre de 2022, las firmas NEWMONT CORPORATION y GLENCORE INTERNATIONAL AG suscribieron un Acuerdo de Compraventa de Acciones por el cual la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG adquirió la totalidad de las acciones de la firma NEWMONT CORPORATION en la firma MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED.

Que, como consecuencia de la transacción, la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG acrecentó su

participación en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED la cual asciende, luego de la operación en consulta, a CUARENTA Y TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (43,75%).

Que el día 1 de noviembre de 2022, se presentó el apoderado de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG, con el fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 27.442 respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación.

Que a fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

Que, asimismo, en el artículo 11 de la mencionada ley, se enumeran los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.

Que para que una transacción deba ser notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, deben cumplirse TRES (3) requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la citada ley; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar.

Que, en el caso analizado, las partes plantean que la operación no cumpliría con el requisito (i), es decir, que no encuadra en la definición de concentración económica, porque no habría cambio de control sobre la empresa objeto.

Que, asimismo, en función de lo consultado, las partes informaron que la facturación total de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG en 2021 superó el umbral legal establecido en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia y que la operación no encuadra en ninguna de las excepciones legales, por lo que se consideran cumplidos los requisitos (ii) y (iii).

Que conforme los actos enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.442, la cual consistió en una adquisición de participación accionaria, el supuesto en el cual podría encuadrar la transacción en consulta es descripto en el inciso c), que consiste, en resumen, en la adquisición de acciones cuando otorgue el control o la influencia sustancial.

Que si bien dicha participación es minoritaria, hay que evaluar si le otorga influencia sustancial en las decisiones estratégicas de la empresa, sobre todo considerando que el joint venture se vio reducido a dos participantes, que ahora detentan el total de las participaciones sociales.

Que, a tal fin, resultó fundamental examinar con detalle el Acuerdo de Accionistas suscripto entre las partes, donde se establecen los términos que regirán el joint venture, la titularidad de las acciones, el fondeo y la realización de las operaciones.

Que en particular, resulta relevante analizar las cláusulas donde se definen qué asuntos requieren para su decisión una votación ordinaria, la que implica una representación superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%),

votación por mayoría calificada que represente el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y votación unánime, donde se reúna el CIEN POR CIENTO (100%) de los votos.

Que el primer efecto significativo de la operación en consulta radicó en que, la firma YAMANA GOLD INC. necesitará indefectiblemente la conformidad de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG para poder tomar todas las decisiones que implican una mayoría calificada del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y las que requieren unanimidad.

Que, en ese sentido se advierte un incremento en la injerencia de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG en la toma de decisiones del joint venture.

Que, en un orden cualitativo, se observó que los asuntos que requieren para su decisión una mayoría calificada, son, por ejemplo: aprobar el programa y presupuesto anual, previo al inicio de producción de la primera mina a construirse; luego del inicio de producción: aprobar el programa y presupuesto del estudio que contemple la preparación de un estudio previo de factibilidad o estudio de factibilidad respecto a una nueva mina o una ampliación significativa; sujeto a ciertas condiciones, la celebración de contratos que superen los DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (US\$ 20.000.000); la suspensión o reducción de la producción en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) o más por un período mayor a TREINTA (30) días, salvo que sea permanente y/o la reanudación de las operaciones; el plan de gestión ambiental, el plan de cierre o cualquier evaluación de impacto ambiental y cualquier enmienda en la medida que aumente significativamente los pasivos; la votación para remover un miembro del equipo administrador o cubrir una vacante en el equipo administrador senior y la aprobación de un plan de vida de la mina.

Que siendo que decisiones que requieren una mayoría ordinaria, mayoría calificada y unanimidad en la votación, se observa que los derechos de veto acordados exceden la simple protección de la inversión del accionista minoritario, ya que le otorgan a la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG una influencia sustancial en la toma de decisiones referidas al giro del negocio.

Que según la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, “Los derechos de veto deben referirse a las decisiones estratégicas sobre la política comercial de la empresa en participación y deben ser más completos que los derechos de veto generalmente concedidos a los accionistas minoritarios a fin de proteger sus intereses financieros como inversores de la empresa en participación. (...) Los derechos de veto que dan lugar al control en común se refieren habitualmente a decisiones y cuestiones tales como el presupuesto, el programa de actividad, las grandes inversiones o el nombramiento de los altos directivos”.

Que, por otra parte, si bien YAMANA GOLD INC puede designar al administrador del joint venture, en caso que YAMANA GOLD INC. deje de ser el accionista mayoritario y Administrador, se debe conformar un nuevo órgano, que debe ser designado por unanimidad, es decir, se necesitará la conformidad de GLENCORE INTERNATIONAL AG -aun siendo accionista minoritario- para decidir quién integrará el nuevo órgano que reemplazará al Administrador.

Que, en consecuencia, de esta previsión pudo inferirse que el hecho de que YAMANA GOLD INC. sea el Administrador, implicó la conformidad del resto de los accionistas, y que no depende exclusivamente de su calidad de accionista mayoritario.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha opinado que “(...) la adquisición de control en común no exige que quien lo adquiere tenga la facultad de ejercer una influencia decisiva en el funcionamiento cotidiano de una empresa. Lo importante es que los derechos de veto permitan a los accionistas

ejercer dicha influencia sobre la estrategia competitiva de la empresa”.

Que de un análisis global del Acuerdo de Accionistas aportado y los derechos que allí se acuerdan, se infiere que la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG, como resultado de la operación, adquiere cuanto menos, influencia sustancial sobre la firma MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED.

Que por lo tanto, puede concluirse que la operación en estudio constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley N.º 27.442, y, por consiguiente, se encuentra sujeta a la obligación de notificar en los términos del artículo 9° de la misma ley.

Que, finalmente, en relación a lo solicitado por la consultante sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N° 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006).

Que, por lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen N° IF-2023-15300743-APN-CNDC#MEC de fecha 9 de febrero de 2023 correspondiente a la “OPI. 346” en el cual recomendó a esta Secretaría: (a) Disponer que la operación traída a consulta, que consiste en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria de NEWMONT CORPORATION en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, por parte de GLENCORE INTERNATIONAL AG se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley N° 27.442, (b) Comunicar al consultante que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N.º 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006), y (c) Hacer saber al consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico correspondiente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.442, y los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hágase saber a la consultante que la operación traída a consulta que consiste en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria de NEWMONT CORPORATION en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, por parte de GLENCORE INTERNATIONAL AG se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley N.º 27.442, en razón de lo dispuesto en los Considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la consultante que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N.º 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006).

ARTÍCULO 3°.- Hágase saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo

que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 4º.- Considérase al Dictamen N° IF-2023-15300743-APN-CNDC#MEC de fecha 9 de febrero de 2023, correspondiente a la “OPI. 346” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, como parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by TOMBOLINI Matias Raul
Date: 2023.02.16 17:48:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.02.16 17:48:38 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI. 346 - Dictamen - Sujeta a Notificación Art.9 Ley 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente N.º EX-2022-117021007- -APN-DR#CNDC, caratulado: "**GLENCORE INTERNATIONAL AG S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442**" (OPI 346) del registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA, iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10º de la Ley N.º 27.442 por parte de la firma GLENCORE INTERNATIONAL AG.

I. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

1. La operación traída a consulta consiste en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria de NEWMONT CORPORATION (en adelante, "NEWMONT") en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED (en adelante, "MARA"), por parte de GLENCORE INTERNATIONAL AG (en adelante, "GLENCORE").
2. Previo a la transacción, MARA estaba integrada por YAMANA con una participación del 56,25%, GLENCORE con una participación del 25% y NEWMONT con una participación del 18,75%.
3. El 17 de septiembre de 2022, NEWMONT y GLENCORE suscribieron un Acuerdo de Compraventa de Acciones por el cual GLENCORE adquirió la totalidad de las acciones de NEWMONT en MARA.
4. Como consecuencia de la transacción, GLENCORE acrecentó su participación en MARA la cual asciende, luego de la operación en consulta, a 43,75%.

5. La parte consultante informa que la operación se cerró el 31 de octubre de 2022.

II. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

II.1. La parte compradora

6. GLENCORE S.A. HOLDINGS LTD es una sociedad constituida conforme las leyes de Bermuda, controlada por GLENCORE INTERNATIONAL AG.

7. GLENCORE INTERNATIONAL AG es una sociedad constituida en Suiza. Es la principal empresa comercial y de cartera del Grupo Glencore, que es una empresa mundial de recursos naturales diversificados. Se dedica al comercio de materias primas y otras mercaderías por cuenta propia y de otras subsidiarias en Suiza y en el extranjero. Asimismo, realiza transacciones financieras, participa en y se asocia con otras empresas. Es controlada por GLENCORE PLC.

II.2. La parte vendedora

8. GOLDCORP CAPITAL CORPORATION es una empresa constituida conforme las leyes de la República de Barbados, se encuentra controlada por GOLDCORP INC.

9. GOLDCORP INC. es una empresa constituida en Delaware, Estados Unidos de América. Está controlada por NEWMONT CORPORATION.

10. NEWMONT CORPORATION es una empresa constituida conforme las leyes de Delaware, Estados Unidos de América. Se dedica a la producción de oro y tiene operaciones de minería en América, África y Australia y en pequeñas cantidades, cobre, plata, zinc y plomo.

II.3. El objeto

11. MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, (en adelante, “MARA”) es un vehículo jurídico holding constituido conforme las leyes de las Islas Caimán. Actualmente, está realizando estudios técnicos para desarrollar el yacimiento de Agua Rica en Adalgalá, provincia de Catamarca en el marco de un nuevo proyecto integrado que permite a nivel local el desarrollo del proyecto MINERA AGUA RICA LLC, SUCURSAL ARGENTINA utilizando la infraestructura de MINERA ALUMBRERA LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA. Previo a la transacción estaba conformada por: YAMANA, con una participación del 56,25%, GLENCORE con una participación del 25% y NEWMONT con una participación del 18,75%.

12. MINERA AGUA RICA LLC, SUCURSAL ARGENTINA, (en adelante, “MAR”) es la

sucursal argentina de MINERA AGUA RICA LLC. Posee propiedades mineras en Andalgalá, provincia de Catamarca. Se encuentra controlada por MARA.

13. MINERA ALUMBRERA LIMITED, SUCURSAL ARGENTINA (en adelante, “MAA”) es la sucursal argentina de MINERA ALUMBRERA. Se encuentra controlada por MARA.

III. EL PROCEDIMIENTO

14. Con fecha 1° de noviembre de 2022, se presentó el apoderado de GLENCORE, con el fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley N.° 27.442 respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación.

15. Con fecha 18 de noviembre de 2022, esta Comisión Nacional, mediante providencia PV-2022-125007302-APN-DNCE#CNDC efectuó un requerimiento al consultante comunicándole que el plazo establecido en el artículo 8° del Anexo I del Decreto N.° 89/2001 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo allí solicitado.

16. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, con fecha 25 de enero de 2023 la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento a todo lo requerido por esta Comisión Nacional, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

IV.1. Planteo de las partes

17. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

10. A modo de antecedente, la parte consultante informa que el 7 de marzo de 2019 YAMANA, GLENCORE y NEWMONT firmaron el Acuerdo de Integración con el objetivo de establecer los términos de la integración de sus participaciones en los activos MAA y MAR a un nuevo joint venture. El objetivo del joint venture consiste en integrar la producción de concentrado de cobre de MAR, mediante el uso de la infraestructura de la mina perteneciente a MAA.

11. El 17 de diciembre de 2020, YAMANA, GLENCORE y NEWMONT CORPORATION; y MARA celebraron un Acuerdo de Accionistas por el cual transfirieron sus tenencias sociales en MAA y MAR al vehículo jurídico holding MARA, cuyo operador es YAMANA¹.

12. En consecuencia, la estructura accionaria de MARA quedaba conformada de la siguiente manera: (i) YAMANA con una participación indirecta del 56,25%; (ii) GLENCORE con una participación indirecta del 25%, y (iii) NEWMONT con una participación indirecta del 18,75%. YAMANA era, según manifiestan las partes, la controlante exclusiva de la empresa.

13. Ahora bien, la operación sobre la que se consulta en estas actuaciones consiste en la adquisición de la participación de NEWMONT en MARA, por parte de GLENCORE. Por lo tanto, luego de la transacción en consulta la estructura accionaria de MARA quedó conformada de la siguiente manera: (i) YAMANA con una participación indirecta del 56,25% y (ii) GLENCORE con una participación indirecta del 43,75%.

14. La parte consultante sostiene que, a pesar del incremento de participación accionaria de GLENCORE en MARA, ésta sigue siendo controlada por YAMANA; es decir, entiende que el escenario de control no ha cambiado en virtud de la presente transacción.

15. Fundamenta lo expuesto en que YAMANA, como accionista mayoritario en MARA, actúa como “Administradora” y, por lo tanto, tiene la responsabilidad general de la gestión diaria de las operaciones del joint venture.

16. Agrega que, si bien tanto YAMANA como GLENCORE pueden designar la misma cantidad de directores en el Comité del joint venture, los votos de los directores serán equivalentes a la participación de cada accionista dividida entre los directores nombrados por ese accionista. Así, GLENCORE aún teniendo igual cantidad de directores que YAMANA, no la igualaría en votos, sino que sus votos representarían un 43,75%.

17. Con relación a los asuntos que requieren para su aprobación un mínimo de votos del Comité que represente un 75% de la participación total, luego de enumerarlos, la consultante afirma que se tratan de mínimos derechos de protección de minorías estándares en la industria minera.

18. Sostienen que, en el escenario anterior a la transacción, YAMANA podía lograr la mayoría del 75% de los votos con el voto de GLENCORE o con el de NEWMONT y que, si bien ese equilibrio se modifica luego de la transacción, los derechos de veto contemplados en el Acuerdo no le otorgan a GLENCORE la capacidad de influir en decisiones estratégicas sobre la política comercial de MARA (sino que se tratarían de mínimos derechos de protección de minorías estándares en la industria minera).

19. En particular, respecto al derecho de veto del programa y presupuesto anual de MARA previo al comienzo de producción de la primera mina, refiere que está sólo disponible en la fase de preproducción y cesa una vez que la mina entre en funcionamiento, y agrega que ese

límite en el tiempo evidencia la función de protección de minorías que conlleva.

20. Con respecto al derecho de veto sobre el Equipo de Alta Dirección (órgano que se conformaría en caso que YAMANA dejara de ser accionista mayoritario), manifiesta que es un acontecimiento extraordinario y que en circunstancias normales YAMANA actúa como Administradora y no existirá el Equipo de Alta Dirección, y por ello GLENCORE no podrá ejercer su derecho de veto.

21. Finalmente, en su presentación solicita a esta CNDC que suspenda el plazo previsto para la notificación obligatoria estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley N.º 27.442 desde la presentación de la solicitud hasta que este organismo emita una opinión consultiva.

IV.2. Análisis

22. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley N.º 27.442, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*

23. A su vez, en el artículo 11° de la mencionada ley se enumeran los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.

24. De lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la CNDC, deben cumplirse tres requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la citada ley; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado; y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar.

25. En el caso en análisis, las partes plantean que la operación no cumpliría con el requisito (i), es decir, que no encuadra en la definición de concentración económica, porque no habría cambio de control sobre la empresa objeto. Asimismo, en función de lo consultado, las partes informaron que la facturación total de GLENCORE en 2021 superó el umbral legal establecido en la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y que la operación no encuadra en ninguna de las excepciones legales, por lo que se consideran cumplidos los requisitos (ii) y (iii).

26. A fin de determinar si la operación consultada está sujeta a la obligación de notificar

conforme el artículo 7° de la ley N.º 27.442, debemos determinar si la transacción implica un cambio en la naturaleza de control sobre el joint venture.

27. Cabe recordar la definición de concentración económica que contiene el artículo citado de la norma que dice: “Art. 7°- A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los siguientes actos: a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre sí misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa; e) Cualquiera de los actos del inciso c) del presente, que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.”

28. Si confrontamos los actos enumerados en la norma con la transacción aquí consultada (que consistió en una adquisición de participación accionaria), el supuesto en el cual podría encuadrar la transacción en consulta es descripto en el inciso c), que consiste, en resumen, en la adquisición de acciones cuando otorgue el control o la influencia sustancial.

29. En ese sentido, se observa que la participación final de GLENCORE, post transacción asciende al 43,75%, que, si bien es minoritaria, hay que evaluar si le otorga influencia sustancial en las decisiones estratégicas de la empresa, sobre todo considerando que el joint venture se vio reducido a dos participantes, que ahora detentan el total de las participaciones sociales.

30. Como ha expuesto esta CNDC en otras oportunidades, *“El control puede ser conjunto aún cuando no exista igualdad entre los accionistas en lo referente a los votos o a la representación en los órganos decisorios o cuando haya más de dos. En este supuesto, los accionistas minoritarios tienen derechos suplementarios que les permiten vetar decisiones capitales para la estrategia competitiva de la empresa en participación.”*².

31. A tal fin, resulta crucial examinar con detalle el Acuerdo de Accionistas suscripto entre las partes, donde se establecen los términos que regirán el joint venture, la titularidad de las acciones, el fondeo y la realización de las operaciones.

32. En particular, resulta relevante analizar las cláusulas donde se definen qué asuntos requieren para su decisión una votación ordinaria (implica una representación superior al

50%), votación por mayoría calificada (refiere a una votación que represente el 75%) y votación unánime (una votación donde se reúna el 100% de los votos).

33. El primer efecto significativo de la operación en consulta radica en que, YAMANA necesitará indefectiblemente la conformidad de GLENCORE para poder tomar todas las decisiones que implican una mayoría calificada del 75% y las que requieren unanimidad. Cuando antes, la mayoría calificada podía obtenerse con la conformidad de NEWMONT o GLENCORE alternativamente. En ese sentido se advierte un incremento en la injerencia de GLENCORE en la toma de decisiones del joint venture.

34. En un orden cuantitativo, se advierte que el listado de asuntos que requieren votación calificada y votación unánime (para los que se requiere a GLENCORE) contempla, en conjunto, 43 ítems; mientras que el listado de asuntos que requiere votación ordinaria (que podría decidir YAMANA por sí sólo) está integrado por 12 ítems. De esto podemos inferir que hay más asuntos que requieren votación calificada y unánime, que los que precisan mayoría ordinaria.

35. En un orden cualitativo, se observa que los asuntos que requieren para su decisión una mayoría calificada (ver cláusula 3.9 del Acuerdo de Accionistas), son, por ejemplo: aprobar el programa y presupuesto anual, previo al inicio de producción de la primera mina a construirse; luego del inicio de producción: aprobar el programa y presupuesto del estudio que contemple la preparación de un estudio previo de factibilidad o estudio de factibilidad respecto a una nueva mina o una ampliación significativa; sujeto a ciertas condiciones, la celebración de contratos que superen los U\$S 20.000.000; la suspensión o reducción de la producción en un 25% o más por un período mayor a 30 días, salvo que sea permanente y/o la reanudación de las operaciones; el plan de gestión ambiental, el plan de cierre o cualquier evaluación de impacto ambiental y cualquier enmienda en la medida que aumente significativamente los pasivos; la votación para remover un miembro del equipo administrador o cubrir una vacante en el equipo administrador senior y la aprobación de un plan de vida de la mina.

36. En cuanto a la aprobación del programa y presupuesto anual antes del comienzo de producción de la primera mina, cabe hacer formular algunas consideraciones. Según lo informado por las partes, las etapas de un proyecto minero son: (i) Exploración, (ii) Desarrollo, (iii) Construcción, (iv) Producción, y (v) Cierre. Considerando que la etapa de producción es la última antes del cierre y en vistas del tiempo que puede tomar llegar a dicha etapa –tégase en cuenta que en la vista del día 25 de enero de 2023 las consultantes informan que la producción podría empezar recién en 2028/2030-, no resulta tan claro que la aprobación del programa y presupuesto anual en todas las etapas anteriores resulte acotada en el tiempo. Desde un punto de vista de decisiones estratégicas, podría pensarse que la mayoría de ellas se toman previo al

inicio de producción, con lo cual los derechos de veto están acordados en las etapas más decisivas del proyecto minero.

37. Entre los asuntos que requieren una votación unánime encontramos, por ejemplo: la adopción de cualquier estudio previo de factibilidad o estudio de factibilidad confeccionado respecto de una mina sobre el proyecto integrado, la aprobación de cualquier programa y presupuesto de construcción o de una ampliación significativa; la celebración de cualquier contrato de streaming de metales, contratos de futuros, ventas a futuro, negociación de opciones de venta de commodities, opciones de compra; la aprobación de códigos y políticas respecto de coberturas de commodities, tasas de interés o moneda, la determinación de la política de comercialización y ventas y el establecimiento de los términos y condiciones de contrato de compra de producción bajo el joint venture, entre otros.

38. A su vez, al analizar las decisiones que se pueden tomar por mayoría ordinaria, se advierte que se trata de decisiones con menor impacto, por ejemplo: la aprobación del programa y presupuesto después del inicio de producción de la primera mina a construirse (excluyendo cualquier otro programa y presupuesto que contemple estudio previo de factibilidad o estudio de factibilidad respecto a una ampliación significativa, o cualquier programa y presupuesto de una ampliación significativa, superior a los U\$S 100.000.000); sujeto a ciertas condiciones, la celebración de contratos cuya obligación de pago supere los U\$S 10.000.000, pero sea inferior a los U\$S 20.000.000; las enmiendas o cambios al plan de gestión ambiental; las modificaciones o enmiendas del plan de vida de la mina.

39. Es consecuencia, constituyen decisiones que implican enmiendas sobre asuntos decididos por mayoría calificada (plan de vida de la mina, plan de gestión ambiental), o cuestiones que implican erogaciones de montos que no superen determinadas sumas, o ampliaciones menores o no significativas.

40. De la lectura de las decisiones que requieren una mayoría ordinaria, mayoría calificada y unanimidad en la votación, se observa que los derechos de veto acordados exceden la simple protección de la inversión del accionista minoritario, ya que le otorgan a GLENCORE una influencia sustancial en la toma de decisiones referidas al giro del negocio.

41. Como tiene dicho esta CNDC, *“Los derechos de veto deben referirse a las decisiones estratégicas sobre la política comercial de la empresa en participación y deben ser más completos que los derechos de veto generalmente concedidos a los accionistas minoritarios a fin de proteger sus intereses financieros como inversores de la empresa en participación. (...) Los derechos de veto que dan lugar al control en común se refieren habitualmente a decisiones y cuestiones tales como el presupuesto, el programa de actividad, las grandes inversiones o el nombramiento de los altos directivos”*³.

42. Por otra parte, si bien YAMANA puede designar al administrador del joint venture, en caso que YAMANA deje de ser el accionista mayoritario (y Administrador) se debe conformar un nuevo órgano, que debe ser designado por unanimidad. Es decir, se necesitará la conformidad de GLENCORE -aún siendo accionista minoritario- para decidir quién integrará el nuevo órgano que reemplazará al Administrador (el Equipo de Alta Dirección). De esta previsión puede inferirse que el hecho de que YAMANA sea el Administrador implicó la conformidad del resto de los accionistas, y que no depende exclusivamente de su calidad de accionista mayoritario. Si el carácter de Administrador dependiera únicamente de su calidad de accionista mayoritario, cualquier accionista mayoritario debería poder ser o designar al Administrador. Sin embargo, no sucede eso, sino que si YAMANA deja de ser accionista mayoritario se conforma un nuevo órgano, que debe ser nombrado con la conformidad unánime de los accionistas.

43. Al respecto, no resulta determinante la probabilidad o improbabilidad de que YAMANA deje de ser accionista mayoritario, y por consiguiente se necesite la conformidad del resto de los accionistas, sino que es suficiente con que exista dicha posibilidad, como tiene dicho esta CNDC, *“no es necesario establecer que quien adquiera el control en común de la empresa hará realmente uso de su influencia decisiva. Basta con que exista dicha posibilidad, es decir, que posea los derechos de veto pertinentes”*⁴.

44. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que los deberes y obligaciones del Administrador consisten principalmente en llevar a cabo los actos pertinentes para adoptar las decisiones del directorio del joint venture. Es decir, si bien está facultado para una serie de cuestiones administrativas, no tendría poder de decisión, sino que resulta un ejecutor de las decisiones tomadas por el Directorio.

45. En cuanto al Directorio, como surge del Acuerdo de Accionistas, establece que deben reunirse como mínimo una vez por trimestre y para su quorum se requiere la presencia de un director por accionista. Asimismo, se acuerda que el rol del directorio es brindar dirección estratégica y supervisar al administrador en la gestión de las operaciones, como así también determinar las políticas, objetivos y asuntos generales del joint venture, incluyendo la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la realización de las operaciones, incluyendo la aprobación de todos los programas y presupuestos y el plan de vida de la mina. Se acuerda también que, si bien el directorio no participará en la gestión diaria de las operaciones, los accionistas deberán procurar que todos los asuntos significativos relativos a las operaciones estén sujetos a la supervisión y dirección del Directorio.

46. En ese sentido, esta CNDC ha opinado que *“(...) la adquisición de control en común no exige que quien lo adquiere tenga la facultad de ejercer una influencia decisiva en el*

funcionamiento cotidiano de una empresa. Lo importante es que los derechos de veto permitan a los accionistas ejercer dicha influencia sobre la estrategia competitiva de la empresa”.

47. De un análisis global del Acuerdo de Accionistas aportado y los derechos que allí se acuerdan, se infiere que GLENCORE, como resultado de la operación, adquiere cuanto menos, influencia sustancial sobre MARA.

48. Por lo tanto, puede concluirse que la operación en estudio constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley N.º 27.442, y, por consiguiente, se encuentra sujeta a la obligación de notificar en los términos del artículo 9° de la misma ley.

49. Finalmente, en relación a los solicitado por la consultante sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N° 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006).

V. CONCLUSIÓN

50. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SECRETARIO DE COMERCIO: (a) disponer que la operación traída a consulta, que consiste en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria de NEWMONT CORPORATION en MINERA AGUA RICA ALUMBRERA LIMITED, por parte de GLENCORE INTERNATIONAL AG se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley N.º 27.442, (b) Comunicar al consultante que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución N.º 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006), y (c) Hacer saber al consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

51. Elévese el presente Dictamen a la SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO para su conocimiento.

¹ La citada transacción fue notificada ante esta Comisión Nacional, lo que dio origen a las actuaciones EX-2020-89588619-APN-DR#CNDC, caratuladas “0805346 BC LTD, GLENCORE INTERNATIONAL AG Y NEWMONT CORPORATION S/NOTIFICACION ART 9 DE LA LEY N° 27.442”, aprobada mediante resolución RESOL-2021-557-APN-SCI#MDP.

² Dictamen CNDC N.º 570/2006, Resolución SCI N.º 13/2006, en el marco de los autos caratulados como “BASF AG Y ENGELHARD CORPORATION (OPI N° 124)”.

³ Dictamen CNDC N.º 570/2006, Opinión Consultiva N.º 124, op cit.

⁴ Dictamen CNDC N.º 570/2006, Opinión Consultiva N.º 124, op cit.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.02.09 11:02:10 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.02.09 11:42:26 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.02.09 14:05:23 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.02.09 15:53:45 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.02.09 15:53:46 -03:00